

1509641-98.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... nº 0008392-32.2007.8.26.0050, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, cuja pena foi extinta em 2018 - exec. Nº 1 - fls. 30; autos nº 0016222-44.2010.8.26.0050, perante a 9ª Vara Criminal Central, extinta em 17/12/2016, fls. 31; e pelo crime de furto, autos nº 0070025-10.2008.8.26.0050, que tramitou perante a 14ª Vara Criminal Central e que foi extinta também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509641-98.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509641-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LEONARD DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

DAVID LEONARD DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, "caput", combinado com art.14, II, ambos do Código Penal, segundo apurado, no dia 19 de abril de 2021, por volta das 16h45min., no estabelecimento comercial denominado GIGA ATACADISTA LTDA., situado na Rua Koshun Takara nº 900, Vila Dionísia, nesta Capital, tentou subtrair, para si, duas peças de carne bovina (contrafilé).

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos o representante da vítima, um policial e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Marcelo, o que foi devidamente homologado em juízo.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu a absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso III ou VI, do Código de Processo Penal, invocando o princípio da insignificância ou ainda a existência do furto famélico, já que o réu estava em estado de miserabilidade à época dos fatos. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena base em seu mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da modalidade tentada do delito no patamar máximo de 2/3, aplicação do

regime de furto privilegiado, fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da combativa Defesa, a absolvição do acusado David à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Preliminarmente, não há que se cogitar a atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, o princípio da insignificância se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

No caso em comento, trata-se de réu reincidente, e portanto, não há como reputar nenhuma periculosidade social de sua ação, ou mesmo o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.

Afastada a aplicação do princípio da insignificância, também não há que se falar em exclusão da ilicitude do fato, em razão de furto famélico, como sugerido pela Defesa, principalmente em razão da quantidade de carne subtraídas e ainda do estado em que se encontravam.

Ademais, conforme se depreende da própria narrativa do acusado ele pagou por algumas frutas que também adquiriu, antes de ser detido, o que coloca pelo menos em dúvida, o que para ele significa estar em "estado de miserabilidade".

Neste sentido:

"As dificuldades financeiras que o acusado alega sofrer não autorizam o reconhecimento de estado de necessidade, consoante reiterado entendimento jurisprudencial: o fato de o agente estar passando por dificuldades, situações da maioria dos brasileiros, não caracteriza o estado de necessidade." (RJDTACRIM

19/99).

De outra banda, no mérito propriamente dito, não há dúvidas de que o réu subtraiu os bens de propriedade da empresa vítima.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação dos bens apreendidos, fotografias acostadas às fls. 20/21, relatório final, bem como pela prova oral produzida durante toda a persecução penal.

A autoria também é incontestada.

O próprio réu ao ser ouvido em juízo, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava em situação de rua e, por necessidade, acabou cometendo o delito. Relatou que passou pelo caixa e pagou pelas laranjas e limões, deixando as carnes na parte de baixo do carrinho. Após tentar sair em posse da res furtiva, foi abordado por funcionários da segurança do supermercado. Atualmente trabalha com reciclagem e está recebendo um auxílio acidente - de R\$ 606,00.

A confissão do réu, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, veio devidamente corroborada pelas outras declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, Lucas Alves Barbosa, policial militar e testemunha, relatou que estava em diligência quando foi irradiado, via COPOM, ocorrência de furto em supermercado. Ao chegarem ao local dos fatos visualizaram o indivíduo já detido pelo segurança do supermercado, em posse da res furtiva. Em conversa com a equipe do supermercado, essa teria relatado que o indiciado teria pagado por um saco de laranja e um de limão, enquanto as carnes teriam ficado na parte de baixo do carrinho. Indagado, o réu teria confessado a prática delitiva.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado, muito pelo contrário, a narrativa policial foi devidamente confirmada pelo próprio autor do crime o que reforça ainda mais a posição adotada por esta magistrada e pela maioria esmagadora da doutrina e jurisprudência, como a seguir se demonstra:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94)

Por sua vez, ouvido em juízo, C. M. P, representante da empresa vítima, afirmou que, na data dos fatos, o averiguado adentrou ao mercado como suposto cliente mas demonstrou suspeita ao passar pelo caixa, fato que fez com que começasse a ser acompanhado de longe. Ao chegar no caixa 21, o réu atravessou com uma embalagem molhada na mão. Ocorre que, ao passar pelas antenas, elas apitaram. Ao ser abordado, o réu assumiu a prática delitiva, dizendo “perdi, perdi”. Afirmar que o averiguado pagou por 3 ou 4 laranjas, mas não pelas peças de carne que estavam em poder dele e indagado, não explicou por qual razão praticou o furto. A polícia foi acionada e apenas compareceu no local para efetuar a prisão em flagrante do réu e conduzir todos ao Distrito Policial. Os produtos estavam avaliados em R\$ 359,00. Ressalta-se, ademais, que a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas

contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento. Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Ora, diante das provas colhidas, não obstante os argumentos da douta defensora, de rigor a condenação do réu.

Caracterizada, portanto, a infração penal, passa-se a dosimetria da pena.

O réu é reincidente conforme certidão de fls. 28/31, já tendo sido condenado definitivamente por crime de furto qualificado, autos nº 0008392-32.2007.8.26.0050, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, cuja pena foi extinta em 2018 - exec. Nº 1 - fls. 30; autos nº 0016222-44.2010.8.26.0050, perante a 9ª Vara Criminal Central, extinta em 17/12/2016, fls. 31; e pelo crime de furto, autos nº 0070025-10.2008.8.26.0050, que tramitou perante a 14ª Vara Criminal Central e que foi extinta também no ano de 2018; exec. Nº 02 - fls. 31.

Assim sendo, a condenação decorrente da sentença proferida perante a 9ª Vara Criminal Central, que somente foi extinta em 17 de dezembro de 2016, dentro ainda do prazo legal previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, será considerada na segunda fase de aplicação de pena.

As outras duas condenações supracitadas, serão tidas como maus antecedentes criminais, o que nos permite aumentar a pena do acusado em 1/5 chegando-se a pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art.59, do Código Penal.

Neste ponto, embora a certidão de fls. 137 aponte que o réu foi condenado nos autos nº 0008907-18.2017.8.26.0050, em pesquisa realizada por esta magistrada verificou-se que tal condenação não é definitiva e assim sendo não será aqui considerada, consoante posição já firmada pela doutrina e jurisprudência.

Na segunda fase de aplicação de pena, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid 19, reconhecida mundialmente e também a atenuante da confissão e assim sendo, como atenuante e agravante se compensam, não há que se falar em alteração da pena.

Neste ponto, apenas a título de fundamentação, respeitadas posições em contrário, embora a pena não tenha sido agravada pelos motivos acima expostos, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, não é o caso de simplesmente se afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime ocorreu durante o estado de calamidade pública da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879/2020), mormente no caso dos autos, momento em que estávamos com um número exorbitante de mortes em nosso país, em razão da pandemia.

Veja-se que a lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida, sendo possível concluir que o legislador entendeu que o cometimento de delitos nas ocasiões excepcionais previstas demonstra o absoluto desprezo e insensibilidade do autor do fato à sociedade, já gravemente vulnerabilizada afetada em termos de saúde, economia, trabalho e perdas pessoais) pandemia e a seus valores, o que dota a conduta criminoso de um grau mais acentuado de reprovabilidade. Como aliás têm se posicionado nossos Tribunais superiores.

Presente também no caso em tela a agravante da reincidência acima apontada, e assim sendo a pena n a pena deve ser aumentada em 1/6, pela reincidência atestada, chegando-se ao patamar de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o crime foi tentado, e neste ponto, considerando que o réu passou pelo caixa pagou apenas por algumas laranjas e tentou sair do local também com as peças de carnes sua pena deve ser diminuída pela 1/2, chegando-se a 08 meses e 12 dias de reclusão, e 7 dias-multa, que serão fixados no mínimo legal estabelecido, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Incabível também a aplicação do disposto no §2º, do art. 155, do Código Penal, diante da reincidência e dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, por expressa vedação legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-se ao réu DAVID LEONARD DE OLIVEIRA SANTOS a pena

de 05 meses e 18 dias de reclusão, e 4 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, notadamente pela reincidência e maus antecedentes atestados nos autos, nos termos do que prevê o art. 33, §3º, do Código Penal.

Neste sentido: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, Dje 11/06/2019).

Inviável é a substituição da pena, de acordo com o art. 44, inciso II, III, e parágrafo 3º, do Código Penal, bem como a aplicação do sursis nos termos do art. 77, caput, do C.P.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Veja-se que no caso em tela o réu já foi beneficiado com a substituição da pena privativa em pena restritiva de direitos e novamente se viu cometendo crime, o que demonstra que

Tendo em vista que respondeu solto por este processo, poderá apelar em liberdade já que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, nesta data.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Condene o réu ao pagamento das custas na forma da lei, já que não há nos autos provas de sua hipossuficiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA